

Desafios da Regulação Pública na Era Digital:
O Papel das Plataformas Digitais como “Legisladores Privados”

Essay Competition

Novas Tecnologias - Inteligência Artificial, Algoritmos e Criptografia

Abril de 2024

Mentoria da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa

Lista de siglas e abreviaturas

RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU 2016/679)

RMD – Regulamento dos Mercados Digitais

VLOP – *Very Large Online Platform*

Resumo: A presente incursão tem em vista a exploração da interação entre o Direito Privado e o Direito Público na era digital, com especial enfoque na regulação das plataformas digitais. Procura-se sistematizar as diferentes formas de regulação, bem como o papel das plataformas digitais como “legisladores privados”, destacando os desafios que a regulação pública enfrenta ao equilibrar os interesses privados e públicos, especialmente em face do poder das plataformas disponíveis globalmente na Internet.

Conclui-se que é necessário desenvolver mecanismos eficazes para garantir a transparência, a equidade e o respeito pelos valores democráticos na era digital, assegurando que o *governance* da tecnologia esteja alinhado com os princípios do Estado de Direito e com a proteção dos direitos dos cidadãos.

Abstract: The purpose of this article is to explore the interaction between private law and public law in the digital age, with a special focus on the regulation of digital platforms. It seeks to systematize the different forms of regulation, as well as the role of digital platforms as "private legislators", highlighting the challenges that public regulation faces in balancing private and public interests, especially in the face of the power of global Internet platforms.

It concludes that it is necessary to develop effective mechanisms to guarantee transparency, fairness and respect for democratic values in the digital age, ensuring that technological governance is aligned with the principles of the rule of law and the protection of citizens' rights.

A reconfiguração da relação entre o Direito Privado e o Direito Público precede a digitalização e manifesta-se já noutros segmentos do sistema jurídico. Esta, porém, veio acelerar a erosão das fronteiras da *summa divisio*. As considerações que se seguem abordam as formas de regulação (i) auto-organizada; (ii) auto-regulada; (iii) autorregulação social; (iv) auto-regulada e regulada publicamente, encontradas nos ambientes moldados pela digitalização, bem como as formas de interação entre o Direito Público e o Direito Privado.

Ora, aqueles que lidam com a ordenação e organização jurídica do vasto domínio da utilização das tecnologias digitais (e das decisões ou modelos de negócio baseados no digital) deparam-se com diferentes tipos de intervenções, sejam elas individuais-privadas, empresariais e ou governamentais. Começarei, destarte, por tentar diferenciar alguns termos, a meu ver, importantes e, posteriormente, recorrerei ao exemplo da regulação das plataformas que levou à desnacionalização de muitos domínios de atividade, especialmente os que têm uma organização global, com uma influência estatal limitada ou apenas parcialmente bem-sucedida, para ilustrar o fenómeno das “plataformas como legisladores privados”. Farei, ainda, uma breve referência ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na União Europeia para mitigar o impacto deste fenómeno, concluindo com uma reflexão crítica.

Por **auto-organização**, refiro-me às medidas tomadas, individual ou coletivamente, para atingir objetivos através do próprio comportamento. Os produtos da auto-organização na Internet são, por exemplo, as mensagens *peer-to-peer*, os blogues distribuídos por cidadãos individuais, ou o desenvolvimento (possivelmente colaborativo) de software, mas também os modelos de negócio desenvolvidos e implementados pelas por empresas (em especial, plataformas). Existem frequentemente, para estas atividades, normas de conduta estabelecidas pelos próprios participantes, tais como obrigações morais ou éticas auto-impostas, ou regras para a publicação e divulgação de blogues ou para software desenvolvido colaborativamente, as quais dizem respeito à forma como os participantes cooperam, especialmente na exploração de modelos de negócio. Assim, utilizo o termo **autorregulação** para este tipo de regras, das quais são exemplo os códigos de conduta ou de comportamento. A autorregulação também pode ser desenvolvida por instituições ou organizações (como as associações) com o objetivo de representar os interesses dos seus membros ou de realizar tarefas para o bem comum.

Emprego o termo “**autorregulação social**” quando a criação de normas sociais influencia não só o comportamento dos indivíduos envolvidos na criação das mesmas, mas também quando terceiros as adotam e, recursivamente, as regras ganham eficácia geral. Aqueles que pretendem reger-se por tais normas, a elas aderir, a cumpri-las, por exemplo, através de um contrato ou outro instrumento juridicamente vinculante. Outros, poderão entender que estas

regras não são juridicamente vinculativas (*soft law*) e, mesmo assim, esperar que cada uma das partes envolvidas as cumpra. O incumprimento da autorregulação social poderá ser socialmente sancionado ou censurado - como, por exemplo, através da cessação de relações comerciais ou do menosprezo dos infratores. No entanto, o termo “**regulação**”, em sentido lato, é comumente utilizado no Direito para qualquer intervenção pública direta (sob a veste e no exercício do *ius imperii*) nas forças de mercado que procure corrigir as suas falhas, independentemente dos meios e fins prosseguidos. Considero justificável utilizar o termo regulação, ainda que em sentido mais estrito (auto-“regulação” social), também para as regras sociais, quando estas se destinarem a ser observadas por destinatários que não estiveram envolvidos na sua formulação. Destarte, se a regulação for efetuada em cooperação entre agentes públicos e privados, tratar-se-á de **regulação híbrida**.

Refiro-me à **autorregulação social publicamente regulada** quando as autoridades públicas confiam na autonomia (relativa) dos membros da sociedade para encontrar soluções, mas também implementam, ao mesmo tempo, medidas regulatórias para assegurar que objetivos (também) de interesse público são observados ou especificamente prosseguidos.

A intervenção estatal com vista à contenção legal da autorregulação pode manifestar-se de várias formas, como por exemplo, sob a forma de estabelecimento de normas comportamentais, legalmente obrigatórias ou meramente incentivadas a adotar, emanadas por estruturas – por exemplo, através de entidades administrativas – criadas especialmente para assegurar que os valores de “mercado livre” e a garantia de uma lógica concorrencial eficiente não constituem o vetor mais relevante de atuação, querendo-se também articular-se com outros valores que merecem uma proteção reforçada, como o interesse público ou o direito dos consumidores.

Numa breve análise da evolução histórica da Internet, esta foi inicialmente acolhida por muitos como um novo meio de desenvolvimento livre. Os intervenientes baseavam-se, em grande medida, numa auto-organização (recorde-se a *netiqueta*) ou autorregulação largamente autónoma. Estas estruturas, fundamentalmente bem-vindas e positivas, tiveram, contudo, repercussões negativas, máxime na assimetria na distribuição de poder no setor da Internet. Muitas das ações e interações espontâneas, desenvolvimentos experimentais observados na fase inicial da Internet foram, em grande parte, amontoados num ambiente comercial, com consequências significativas que levaram a esta mudança de paradigma. Tal evolução caracterizou-se, em particular, pela centralização de muitos domínios - (em vez de cada utilizador ter o seu próprio espaço na rede, utiliza intermediários para ter o seu “próprio” espaço na rede).

Logrando uma análise mais aprofundada sobre a evolução da Internet e a sua relação com o Direito, (que pecaria necessariamente por defeito na presente incursão), escrevo *in media res* sobre a atual predominância da regulação não-pública da Internet pelos operadores globais – a supremacia destes em muitos dos domínios marcados pela digitalização e, em particular, pela sua predominância quase monopolista, através de empresas globalmente ativas no campo das plataformas. A regulação mediante a utilização de formas de auto-organização e autorregulação por parte das mesmas molda a concepção dos serviços que prestam, primariamente alinhados com os interesses da empresa e secundariamente - quando tal se revelar útil¹ aos interesses dos cidadãos.

Até à data, não foi possível dismantelar as consideráveis assimetrias de poder, sequer, do mesmo modo, assegurar de forma abrangente um justo equilíbrio dos interesses privados, que proteja simultaneamente e de forma adequada os demais interesses coletivos. É igualmente questionável se as regras estabelecidas pelas próprias plataformas visam, ainda que de forma básica, alcançar um nível de proteção do interesse público, que o Estado de Direito deveria visar, através da regulação pública da autorregulação. É igualmente notória a falta de instrumentos públicos eficazes para garantir a transparência e o controlo dos algoritmos² destas plataformas, principalmente no que toca à interferência na formação autónoma da opinião dos cidadãos e no funcionamento dos processos de decisão democráticos³.

As ameaças são particularmente persistentes nos domínios de atividade dos intermediários, especialmente nas suas plataformas. As FAANG⁴, como atores centrais da Internet atual, têm como principais áreas de regulação, por um lado, a organização do setor privado e dos mercados, nos quais elas próprias coordenam os processos de mercado e determinam as condições de concorrência.

Simultaneamente, assumem funções de organização e regulação social de grande alcance na Internet. Tal facto é descrito⁵ como a *curadoria das condições sociais e do comportamento social*. Além disso, as empresas têm vindo a estabelecer bases para uma “*socialidade*” na

¹ A título de exemplo, Elon Musk instrumentalizou o *Twitter Files*, justificando a aquisição do Twitter (agora X) em prol da liberdade de expressão, um interesse público dos cidadãos.

² Num sentido mais lato, o problema da distribuição do poder inclui também a questão de saber até que ponto existem direitos de acessos aos dados ou sistemas algorítmicos e de os utilizar no seu próprio interesse – inversamente, questiona-se: em que medida existem direitos exclusivos sobre os dados ou sistemas algorítmicos e sobre os produtos criados ou até mesmo comportamentos tornados possíveis com a sua ajuda?

³ GORWA, R.; BINNS, R.; KATZENBACH, C. (2020). *Algorithmic content moderation: Technical and political challenges in the automation of platform governance*. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/2053951719897945>

⁴ Acrónimo de Facebook (agora, Meta), Amazon, Apple, Netflix e Google (agora, Alphabet).

⁵ Esta terminologia é também utilizada no *position paper* da GERMAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES LEOPOLDINA (2021): *Digitalisation and Democracy*. Disponível em https://doi.org/10.26164/leopoldina_03_00407.

Internet organizada pelo sector privado. Consequentemente, não só a maioria das atividades económicas, mas também uma grande parte das interações público-privadas baseadas na Internet, ocorrem agora em espaços organizados e projetados pelo setor privado e, dentro de um quadro técnico e socioeconómico orientado para os interesses desse setor.

É possível caracterizar as plataformas dominantes nesta área como grandes infraestruturas sociotécnicas digitais, baseadas em dados e estruturadas em algoritmos⁶, questão utilizadas para trocar informações, estruturar a comunicação, organizar o trabalho e os mercados, fornecer uma ampla gama de serviços e distribuir produtos digitais e não digitais. A organização dos mercados e a influência nos contextos sociais são as características fundamentais que tornam as plataformas disruptivas e que podem ser identificadas como entidades reguladoras centrais. A regulação destes mercados, organizados pelos intermediários, é feita através de uma extensa regulamentação sociotécnica (incluindo regras de mercado e de concorrência, mecanismos de coordenação, controlo e exploração), que é, por um lado, definida em convenções comerciais e de utilização ou orientações de desenvolvimento e que, por outro, se traduz em programas e instruções técnicas fornecidos pelos *operadores* das plataformas⁷. A aplicação das regras de mercado e a coordenação e tratamento específicos de todos os processos são controladas por algoritmos e, por conseguinte, em grande medida automatizados⁸.

Os operadores de plataformas não atuaram como intermediários neutros, mas antes como atores que definiram as regras, dando prioridade aos seus interesses, e se dotaram de poderes e oportunidades de intervenção de grande alcance. A infraestrutura técnica por estes fornecida não se trata de uma arquitetura neutra que serve “apenas” como *infraestrutura*, para criar ligações, mas antes que constitui a *base institucional* desses mercados, orientando a ação e estruturando os processos através das regras nelas inscritas, às quais os fornecedores, os consumidores e os utilizadores – incluindo o Estado – devem aderir se quiserem participar. Enquanto as regras nas sociedades democráticas ganham geralmente forma no debate público (“política”), e reclamam legitimação democrática, as regras criadas pelas principais empresas de tecnologias dificilmente podem ser negociadas publicamente ou moldadas *ex ante*.

⁶ Vide DOLATA, Ulrich (2020). *Platforms – Regulation: Coordination of Markets and Curation of Sociality*, p. 79 e seguintes. Disponível em: <https://www.econstor.eu/handle/10419/218821>

⁷ Vide KETTEMANN, Matthias C. (2020). *The Normative Order of the Internet*. Oxford University Press. Disponível em <https://academic.oup.com/book/39694/chapter/339702965>

⁸ GORWA, R.; BINNS, R.; KATZENBACH, C. (2020). *Algorithmic content moderation: Technical and political challenges in the automation of platform governance*. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/2053951719897945>

Aliás, mesmo que estejam inscritas em regras técnicas, não são legitimadas democraticamente⁹- e na melhor das hipóteses, só podem ser controladas de forma limitada¹⁰. Relativamente à situação atual, vários autores afirmam que as funções de partilha de informações e de correspondência das plataformas digitais estão indissociavelmente relacionadas com o estabelecimento de instituições e regras segundo as quais os utilizadores, das plataformas, interagem entre si, na plataforma¹¹.

Estas atuam, por assim dizer, como “**legisladores privados**” dos mercados que criaram, estabelecendo regras para a regulação do comportamento do mercado que se destinam, muitas vezes, a moldar a relação entre terceiros.

Por um lado, a “legislação privada” das plataformas não pode ser circunscrita ao conceito restrito que abrange apenas os *Terms & Conditions* das mesmas. Pelo contrário, uma parte significativa das regras de interação de uma plataforma é moldada na sua arquitetura ou concepção. As regras formais e informais de interação, incluindo os seus efeitos de incentivo e controlo, devem ser tidas em conta (tal inclui, também, os sistemas de classificação da própria plataforma, os sistemas de recomendação de conteúdo baseados em *addictive dopamine feedback loops*, a integração dos sistemas de pagamento próprios e externos da mesma e, ainda, os centros de resolução de litígios).

As plataformas digitais também estabeleceram regras para as transações que são processadas através das plataformas. Por exemplo, as condições gerais do *eBay* contêm as regras sobre a celebração de contratos entre as partes que nele operam; já a *Uber* estabelece as regras para os contratos de transporte celebrados através da plataforma. Sublinho a particular necessidade de intervenções públicas legislativas que determinem regras gerais de conduta para as plataformas, em especial sobre a “legislação privada” oriunda de plataformas de grande importância social, política ou económica, para cuja utilização não existem opções alternativas suficientes na perspetiva do indivíduo¹².

No entanto, há que acrescentar: o grande alcance do poder regulador dos operadores globais da Internet – através de autorregulação social – não ocorre numa área que é, ainda hoje, completamente livre de regulação soberana. A regulação pública limitadora da autorregulação

⁹ AA. VV. (2020). *Governing Platforms - Are Algorithms a Threat to Democracy? The Rise of Intermediaries: A Challenge for Public Discourse*. Disponível em: <https://algorithmwatch.org/en/wp-content/uploads/2020/05/Governing-Platforms-communications-study-Stark-May-2020-AlgorithmWatch.pdf>

¹⁰ Se existe procura de quem “não gosta”, o livre mercado criará uma plataforma para esse público-alvo, numa aceção puramente Keynesiana. *Quid juris* o Estado perde o monopólio da força, e os sujeitos apenas se regem pelas “leis” das plataformas?

¹¹ NAKHJAVANI, Ali (2023). *Limitations of digital platforms in EU Digital Markets Act*. In Journal of Legal Research. Disponível em: https://jlr.sdil.ac.ir/article_164158_en.html

¹² Objetivo esse incluído no RMD.

inclui, por exemplo, o RGPD e respectivas leis nacionais de execução, bem como a legislação em matéria em Direito de Propriedade Intelectual, nomeadamente Direito de Autor. O direito da concorrência, em particular, o *antitrust*, também deve ser mencionado¹³.

O RMD tem por objetivo garantir condições de concorrência equitativas para todas as empresas digitais, independentemente da sua dimensão, visando garantir um setor digital competitivo e justo¹⁴. Contudo, a exequibilidade dessa regulamentação está limitada ao domínio de aplicação, (material e subjetiva), da respetiva legislação nacional e da União. A este respeito, é de saudar o facto de tanto o RGPD como o RMD, relativamente ao seu âmbito de aplicação territorial, preverem expressamente que a prestação de serviços nos mercados afetados está vinculada às normas da UE, independentemente do local de estabelecimento da plataforma.

Porém, devo sublinhar que os novos regulamentos não dizem respeito a todas as áreas que acredito necessitarem de regulamentação, nem cobrem todas as dimensões importantes. O poder dos intermediários, e das plataformas em particular, visa impor a mercantilização de dados e a comercialização das vastas áreas da vida, aumentando o seu poder de mercado e tendo um impacto duradouro na formação de valores sociais e na opinião pública¹⁵. Para além do supramencionado, impede, ao mesmo tempo, a transparência sobre a sua própria conduta empresarial e, portanto, também a controlabilidade externa (*accountability*).

Concluo com a seguinte frase: A influência das VLOPs na sociedade excede a dos Estados democráticos em várias dimensões, sem, contudo, estar sujeita a uma participação ou controlo democrático efetivo, não estando as plataformas coerentemente vinculadas aos princípios do Estado de Direito, pelas razões expostas ao longo da incursão.

¹³ Iconicamente, *United States of America v. Microsoft Corporation*, 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001).

¹⁴ Através de mecanismos como, entre outros, a proibição das práticas desleais das plataformas online que detêm a maior quota de mercado e a imposição de direitos e obrigações claros às grandes plataformas

¹⁵ Vide SALES DA CUNHA, Patricia Alvarez (2020). *O Caso Cambridge Analytica e a Privacidade de Dados no Facebook*. (Dissertação de Mestrado em Segurança da Informação e Direito no Ciberespaço). Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa. Disponível em: <https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1126295043838300/Resumo%20Alargado%20Dissertacao%20IST%20ingles.pdf>

Lista Bibliográfica:

- AA. VV. (2020). *Governing Platforms - Are Algorithms a Threat to Democracy? The Rise of Intermediaries: A Challenge for Public Discourse.*
- ASCENSÃO, J. (1977). *O Direito – Introdução e Teoria Geral*, Fundação Calouste Gulbenkian
- CENNAMO, C.; SANTALÓ, J. (2013). *Platform Competition: Strategic Trade-offs in Platform Markets.* In Strategic Management Journal
- CHRISTENSEN, C. M.; RAYNOR, M.; MCDONALD, R. (2015). What Is Disruptive Innovation? In Harvard Business Review
- CHRISTENSEN, C.M. (1997). *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail.*
- CORNILS, M. (2020). Designing Platform Governance: A normative perspective on needs, strategies, and tools to regulate intermediaries. Algorithm Watch.
- COUNCIL OF EUROPE (2016). Draft: Guidelines on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data in a World of Big Data.
- DANAHER, J. (2016). *The Threat of Algocracy: Reality, Resistance and Accommodation.* In Philosophy and Technology, 29 (3):245-268.
- DOLATA, Ulrich (2020). *Platforms – Regulation: Coordination of Markets and Curation of Sociality*
- DOMMERING, E. (2006). *Regulating Technology: Code Is Not Law* DOMMERING, E.; ASSCHER, L. (Hrsg.) (2006). *Coding Regulation: Essays on the Normative Role of Information Technology.*
- ENISA (EUROPEAN UNION AGENCY FOR NETWORK AND INFORMATION SECURITY) (2015). *Privacy by design in big data. An overview of privacy enhancing technologies in the era of big data analytics.*
- FLORIDI, L. (2018). *Soft Ethics, the Governance of the Digital and the General Data Protection Regulation.* In Philosophical Transactions of the Royal Society
- GERMAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES LEOPOLDINA (2021): *Digitalisation and Democracy.*
- GORWA, R.; BINNS, R.; KATZENBACH, C. (2020). *Algorithmic content moderation: Technical and political challenges in the automation of platform governance*
- KETTEMANN, Matthias C. (2020). *The Normative Order of the Internet.* Oxford University Press
- LANGLEY, P.; LEYSHON, A. (2016). *Platform capitalism: the intermediation and capitalization of digital economic circulation.*
- LATORRE, A. (1978). *Introdução ao Direito*, Livraria Almedina Coimbra

- LATZER, M.; HOLLNBUCHNER, K.; JUST, N.; SAURWEIN, F. (2016). *The economics of algorithmic selection on the Internet*.
- LEENES, R.E. (2012). *Framing Techno-Regulation. An exploration of State and Non-state Regulation by Technology*.
- LESSIG, L. (1999/2001). *Code and Other Laws of Cyberspace*.
- LESSIG, L. (2006). *Code Version 2.0*.
- MUSIANI, F. (2013). *Governance by algorithms*.
- OERMANN, M.; ZIEBARTH, L. (2015). *Interpreting code – Adapting the methodology to analyze the normative contents of law for the analysis of technology*. In *Computer Law & Security Review*
- RODRIGUES, A. (2023). *Manual de Inovação Financeira – Uma Introdução ao Universo das Criptomoedas e da Blockchain*, AAFDL Editora
- SALES DA CUNHA, Patricia Alvarez (2020). *O Caso Cambridge Analytica e a Privacidade de Dados no Facebook*.
- SARAIVA R. (2021). *Direito dos Mercados Financeiros – Apontamentos*, (2.º edição, 2.º reimpressão) AAFDL Editora